

组织他人偷越国(边)境使用”,故其行为也不构成骗取出境证件罪。

本案中,持APEC 商务旅行卡的中国公民在旅行卡有效期内凭旅行卡与旅行卡相关联的有效护照,即可多次自由往来于我国与相关经济体之间。若不对出售APEC 商务旅行卡的行为进行刑事处罚,切断出售出境证件牟利的犯罪通道,可能会让一些不法分子有机可乘,不仅会衍生其他犯罪,不利于社会治理,也会对国家安全产生一定威胁,并有损我国国际形象。

苏某某作为熟悉外事程序的工作人员,明知APEC 商务旅行卡的办理要求、流程和功能,为谋取私利,伙同朱某以远超正常申办费用的价格,肆意帮助数十名不符合申领条件的购卡人伪造材料申办取得APEC 卡,其行为已经对我国出境证件的管理秩序产生严重危害,符合出售出境证件罪的构成要件,苏某某、朱某的行为均构成出售出境证件罪。

编写人:江苏省南京市中级人民法院 刘庆琼 钟慧钊

虚构劳动关系为外国人提供入境居留服务的定性分析

——包某某组织他人偷越国(边)境、出售出境证件案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01刑终1号刑事裁定书

2. 案由:组织他人偷越国(边)境罪、出售出境证件罪

【基本案情】

2016年至2019年，被告人包某某或独自招揽或经他人介绍，虚构境外外籍人员与国内公司的劳动关系材料，分别帮助伊某、康某、艾某等多名外籍人员申请外国人工作许可通知，后外籍人员持相关材料申请中华人民共和国Z字签证（职业签证），并持骗领的签证入境后，由包某某安排人员陪同外籍人员至出入境管理部门办理居留申请，获得相关公司工作类居留许可后，均未实际在相关公司工作。

2016年至2019年，被告人包某某为牟取利益，或独自招揽或经他人介绍，为已经在境内的外籍人员虚构与国内公司之间的劳动关系材料，由包某某安排人员陪同外籍人员至出入境管理部门办理居留申请并收取费用，帮助奥某、本某、卡某等多名外籍人员因此获得工作类居留许可后在我国境内居留，并收取费用，外籍人员均未实际在相关公司工作。

2020年1月18日，被告人包某某被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年2月25日被取保候审。

2021年12月24日下午，被告人包某某在取保候审期间与他人意欲偷渡至A国，途经检查点时走山路绕行，先后绕过某检查点。当日19时20分许遇执勤巡逻人员检查，被告人包某某至某加油站对面菜地简易棚躲藏。次日17时许，被告人包某某被公安人员抓获。

【案件焦点】

1. 以代办签证、出入境材料为业务的中介公司，通过帮助外国人虚构劳动关系，骗取工作许可，进而申领工作类签证并入境，是否构成组织他人偷越国（边）境罪；2. 以前述方式，帮助已经在境内旅游或留学的外国人继续在境内居留，是否构成出售出入境证件罪；3. 上述两类行为，是否应数罪并罚。

【法院裁判要旨】

上海市松江区人民法院经审理认为：被告人包某某伙同他人多次组织他人偷越国（边）境且组织人数众多，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪；

又伙同他人出售出入境证件，情节严重，其行为已构成出售出入境证件罪；又违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重，其行为已构成偷越国(边)境罪。被告人包某某在判决宣告前犯数罪，应依法数罪并罚。现有证据足以认定，被告人包某某在组织他人偷越国(边)境罪及出售出入境证件罪中均起主要作用，系主犯。被告人包某某到案后没有如实供述组织他人偷越国(边)境及出售出入境证件的基本犯罪事实，如实供述了偷越国(边)境的犯罪事实，对该节事实可从轻处罚。被告人包某某偷越国(边)境未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、作用及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》相关规定，判决：

一、被告人包某某犯组织他人偷越国(边)境罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币10万元及驱逐出境；犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；犯偷越国(边)境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币20.5万元及驱逐出境；

二、扣押在案的电脑、手机、伪造的身份证等涉案物品，予以没收；

三、未退出的违法所得，继续予以追缴。

宣判后，包某某向上海市第一中级人民法院提出上诉。上海市第一中级人民法院同意一审法院裁判意见。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》作出裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家移民局于2022年6月联合发布《关于依法惩治妨害国(边)境管理违法犯罪的意见》(以下简称《2022年意见》),以回应当前我国妨害国(边)境管理违法犯罪的发展变化与样态特征。

上海作为我国重要的出入境城市，一方面促进维护国际人员交流往来，另一方面也要加强治理防范破坏国(边)境管理秩序的行为。

本案中，被告人包某某伙同他人分别对尚在境外和已在境内的不同外籍人员实施了上述两类行为，分别符合组织他人偷越国(边)境罪、出售出入境证件罪的构成要件，应当数罪并罚。

一、包某某的部分行为构成组织他人偷越国(边)境罪

首先，包某某的行为不仅具有社会危害性，还具有刑罚处罚的必要性。目前，此类通过骗取入境证件的行为已在很大程度上形成了产业化，具有相当程度的典型性。①2021年，国家移民局管理机构依法查处“三非”(非法入境、非法居留、非法就业)外国人7.9万人，遣返比例与2020年相比上升了21%。②被告人对外籍人员不作选择、不加甄别帮助其骗取相关入境证件，使多名在境外的外籍人员通过不法途径进入我国境内，违反了我国出入境管理的相关规定，侵害了我国边境管理制度，破坏了出入境管理的秩序。而且，这些外籍人员入境后多非法从事外教工作，有的还存在违法犯罪行为，对我国外教体系、社会秩序形成了负面的影响。

其次，包某某帮助外国人骗取的工作许可通知是外国人取得Z字签证的关键条件，也是这些外国人得以在境内非法居留的必要条件。根据2012年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《2012年解释》)，使用以虚假的出入境事由、隐瞒真实身份、冒用他人身份证件等方式骗取的出入境证件出入国(边)境的应当认定为偷越国(边)境行为。本案中，外籍人员持骗取入境证件，以表面合法的形式掩盖非法越境目的的行为，属于偷越国(边)境行为。

最后，包某某在本案中有领导、策划、指挥行为，具有“组织性”。根据《2022年意见》第二条的规定，组织他人通过虚构事实、隐瞒真相等方式掩盖非法出入境目的，骗取出入境边防检查机关核准出入境的行为，应当认定为《中华

①许浩：《以提供虚假证明、邀请函件等方式骗取入境证件行为的定性问题》，载《人民法院报》2022年9月15日，第6版。

②喻海松：《偷渡犯罪刑法规制的理念调适与实务展开——以〈关于依法惩治妨害国（边）境管理违法犯罪的意见〉为中心》，载《政治与法律》2023年第3期。

《中华人民共和国刑法》第三百一十八条规定的“组织他人偷越国(边)境”行为。本案中,是否具有“组织性”是判断行为人是否构成组织他人偷越国(边)境罪的关键。非法入境外籍人员的大量证言证实,包某某实际经营的沃风公司主要业务是“给外国人办理签证服务”,即通过给外国人挂靠公司、虚构劳动关系或者帮助外国人在中国注册公司的方式,使外国人取得行政部门签发的工作许可通知,凭此通知在境外申请获得Z字签证和工作类居留许可。包括对外招揽客户,与他人合作;安排员工分工配合;为外国人编写劳动合同;代为向行政管理部门申办工作许可通知并寄送;帮助外国人办理注册公司的所有事宜;准备申签材料;安排接机、陪同递交材料;代缴虚构岗位的社保款、税款;安排工作人员陪同出入境管理部门办理工作类居留许可等。包某某直接全程参与、策划外国人入境或居留事宜,为牟取利益以公司的名义提供一系列中介服务,在较长时间内为“三非人员”代办入境、居留,对外招揽生意,对内领导员工,形成密切配合有组织的完整犯罪链条,全程策划、帮助外籍人员完成偷越国(边)境行为,牟取非法利益,这一系列行为已具备专业化、全链条、一站式的特征,这种有架构的产业化经营模式,符合组织性犯罪的本质特征。

综上,包某某明知外籍人员不具备申请工作签证入境的条件,仍实施上述行为帮助外籍人员入境,根据主客观相一致的原则,其行为符合组织他人偷越国(边)境罪的构成要件。

二、包某某的部分行为构成出售出入境证件罪

上述行为针对的是在境外的意欲入境的外籍人员,对于因旅游、留学等合法入境后签证即将到期无法通过正常途径获得工作类居留证件的外国人,包某某实施的帮助外国人骗取工作许可、工作类居留证件从中非法牟利的行为如何定性,争议较大。

首先,工作类居留许可属于出入境证件。结合相关规定,出入境证件是指护照、代替护照使用的国际旅游证件、中华人民共和国海员证、中华人民共和国出入境通行证、中华人民共和国旅行证、中国公民往来香港、

澳门、台湾地区证件、边境地区出入境通行证、签证、签注、出国(境)
证明、名单，其他

出入境时需查验的资料。外籍人员应当在签证注明的期限申请居留证件，工作许可是申请工作类居留许可的必要条件，而持有工作类居留许可的外国人在居留许可的有效期限内不限次数的出入境。因此，工作类居留许可属于出入境时需要查验的资料，应当认定为出入境证件。根据出境入境管理法的规定，非法居留、非法就业的外国人，公安机关或边防检查机关可以将其遣送出境，而骗领的工作类居留证件使这些外国人保持非法留在境内状态，因此该行为也具有相应的社会危害性和应受刑法处罚的必要性。

其次，包某某全链条参与、全程协助他人骗取入境证件并收取费用的行为可以认定“出售”出入境证件罪。司法要运用稳定的法律调整不断变化发展的社会，需要对法律进行一定解释。对于“出售”的理解，其文义解释是商品与货币的交换形式。行为人通过代为设立公司、伪造劳动合同、代理记账等方式完成相应的手续帮助外籍人员获取居留许可，将本属于行政审批事项的证件通过虚假手续骗取后交付外籍人员获取利益。该行为虽与传统意义上的出售行为形式上存在不同，但究其本质，是将居留许可等证件作为一种物品转售给不具备办理资格的申请人从中获利，仍是一种有偿转让的出售行为，符合出售的客观表现形式。将采用伪造劳动关系，虚构工作许可的方式为已经入境的外国人骗领工作居留证件并收取费用的行为解释为出售出入境证件，符合立法目的和现有规制体系内容，且行为对出入境证件管理秩序的侵犯程度与出售出入境证件罪相当。需要注意的是，对于单纯出售虚假证明、邀请函件，并不参与后续骗取入境证件环节的行为，因虚假证明、邀请函件并不属于出入境证件，故不宜认定为出售出入境证件罪。

三、包某某分别实施组织他人偷越国(边)境和出售出入境证件行为，应当数罪并罚

一种观点认为，对包某某应当以组织他人偷越国(边)境罪或者出售出入境证件罪择一重罪论处。另一种观点认为，包某某实施了针对不同的

对象，实施了数个行为，侵犯了不同的法益，分别符合组织他人偷越国(边)境及出售 出入境证件的构成要件，应分别定罪。

本案生效裁判采纳第二种观点。从表面上看，包某某为每个外国客户提供的服务内容具有类似性，但根据行为的对象不同，可以分为：针对需要非法入境的外国人和针对已经在境内需要非法居留的外国人两种类型。对象不同导致行为的手段、需要提供的证件、办理的手续上均存在差异，存在不存